

서울고등법원 2023. 11. 28. 선고 2023노2371 판결

【성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(촬영물 등 이용 협박)·협박·스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반】,
[미간행]

【전문】

【피 고 인】 피고인
【항 소 인】 쌍방
【검 사】 이세희(기소), 최성완(공판)
【변 호 인】 변호사 이치원

【대상판결】

【원심판결】 인천지방법원 2023. 7. 13. 선고 2022고합385 판결

【주문】

피고인과 검사의 항소를 모두 기각한다.

【이유】

1. 항소이유의 요지

가. 피고인

1) 사실오인, 법리오해

원심 판시 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(촬영물 등 이용 협박)죄와 관련하여, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(이하 ‘성폭력처벌법’이라 한다) 제14조의3 제1항 은 ‘촬영물 또는 복제물을 이용하여 협박한 자’를 가중하여 처벌하는데, ① 이때 ‘촬영물 또는 복제물’은 위 조항의 입법 경위와 법정형 및 같은 법 제14조 제2항 , 제1항 이 규정한 내용 등에 비추어 ‘촬영대상자의 의사에 반하여 촬영한 촬영물 또는 복제물’로 한정하여 해석하여야 하고, ② ‘촬영물 또는 복제물을 이용’하는 행위의 당연한 전제로서 범행 당시 촬영물 또는 복제물이 현존하여야 하며, 협박 당시 촬영물 또는 복제물이 현존하지 않는 경우까지 위 조항으로 처벌하는 것은 죄형법정주의에 반한다. 그런데도 이와 다른 전제에서 이 부분 공소사실을 유죄로 판단한 원심판결에는 사실오인 내지 법리오해의 위법이 있다.

2) 양형부당

원심의 형(징역 10월에 집행유예 2년 등)은 너무 무거워서 부당하다.

나. 검사

1) 사실오인, 법리오해(무죄 부분)

스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반의 점과 관련하여, 피고인은 피해자와 피해자의 남편이 더 이상 연락하지 말라는 뜻을 전달한 이후에도 피해자에게 연락하였는데, 피해자로 하여금 피고인과의 관계를 끊지 못하게 할 의도도 있었으므로 그러한 행위에 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다. 그런데도 이와 달리 정당한 이유를 인정하여 이 부분 공소사실을 무죄로 판단한 원심판결에는 사실오인 내지 법리오해의 잘못이 있다.

2) 양형부당

원심의 형은 너무 가벼워서 부당하다. 원심이 피고인에 대한 신상정보의 공개·고지 명령, 취업제한 명령을 면제한 것도 부당하다.

2. 피고인의 사실오인 및 법리오해 주장에 대한 판단

가. 원심의 판단

피고인은 원심에서도 같은 취지의 주장을 하였다. 원심은 아래와 같이 성폭력처벌법 제14조의3 제1항의 구성요건에 대하여 해석한 다음 원심이 채택·조사한 증거에 의해 인정할 수 있는 사실들을 종합하면 피고인이 원심 판시 범죄사실 기재와 같이 피해자의 음부 사진을 이용하여 피해자를 협박한 사실이 인정된다고 보아 피고인의 주장을 배척하였다(원심판결문 제5~10면).

1) 성폭력처벌법 제14조의3 제1항은 ‘성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 촬영물 또는 복제물을 이용하여 협박한 자’라고 규정하고 있을 뿐, ‘촬영대상자의 의사에 반하여 촬영한 촬영물 또는 복제물’이라고 규정되어 있지 않아 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 촬영물 또는 복제물 외에 촬영대상자의 의사에 반할 것을 요건으로 하지 않음이 문언상 명백하다. 위 제14조의3 제1항은 실제 생성된 촬영물의 유포가능성을 해악의 내용으로 하여 상대방을 협박하면 상대방이 현실적으로 느끼는 공포감이 매우 크기 때문에 ‘촬영물 이용 협박죄’를 ‘단순 협박죄’에 비해 중하게 처벌하는 것으로, 촬영물의 유포가능성으로 인한 공포감은 촬영물이 촬영대상자의 의사에 반하였는지 여부에 따라 근본적으로 달라진다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 사진을 피해자가 스스로 촬영하였다고 하더라도 피고인의 행위가 위 제14조의3 제1항에 해당한다.

2) 성폭력처벌법 제14조의3 제1항에서 정하는 ‘촬영물을 이용한 협박’은 그 취지에 비추어 상대방에게 실제 생성된 촬영물의 유포가능성을 해악의 내용으로 고지하는 것을 의미하는 것으로 해석하여야 하고 그러한 해악의 내용을 고지하면 충분하므로 실제로 촬영물을 유포할 수 있는지는 ‘촬영물 이용 협박죄’ 성립에 영향을 미치지 않는다. 따라서 협박 시점에 촬영물이 실제 존재하지 않거나 피고인이 촬영물을 유포할 수 없는 상태에 있다고 하여도 피해자가 그 사실을 알지 못하는 이상, 촬영물의 유포가능성이 있는 것으로 생각될 수 있는 정도의 구체적인 해악을 고지하였고 그것이 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도라면, 위 규정에서 정한 구성요건에 해당한다고 보아야 한다.

3) 피해자는 2021. 10. 16.경 피고인에게 자신의 음부를 촬영한 이 사건 사진을 보냈고 피고인은 2021. 11. 27. 피해자와 전화통화를 하면서 ‘사진을 다 복원시키겠다’고 말한 점, 피고인은 이 사건 당시 이 사건 사진을 캡처해냈다는 취지로 말한 점, 피해자가 이 사건 당일 저녁에 피고인을 만나 피고인의 휴대전화에 사진이 있는지 확인한 점에 비추어 피해자는 적어도 이 사건 당시에는 사진이 실제 존재하지 않은 사실에 대하여 알지 못하였던 것으로 보인다. 피고인이 사진의 유포가능성이 있는 것으로 생각될 수 있는 정도의 구체적인 해악을 고지하였고, 그것이 피해자로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도라고 보이므로 촬영물을 이용하여 피해자를 협박하였음이 인정된다.

나. 이 법원의 판단

원심이 실시한 사실들을 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들 및 아래와 같은 관련 법리 등에 비추어 면밀히 살펴보면 원심의 판단은 정당한 것으로 충분히 수긍할 수 있다. 거기에 사실을 오인하거나 법리를 오해한 잘못이 없으므로 피고인의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

1) 형법규정은 문언에 따라 엄격하게 해석·적용하여야 하고 피고인에게 불리한 방향으로 확장해석하거나 유추해석을 하여서는 안 된다. 다만 문언이 가지는 가능한 의미의 범위 안에서 규정의 입법 취지와 목적 등을 고려하여 문언의 논리적 의미를 분명히 밝히는 체계적 해석을 하는 것은 죄형법정주의의 원칙에 어긋나지 않는다(대법원 2020. 8. 27. 선고 2019도11294 전원합의체 판결 등 참조).

2) 성폭력처벌법 제14조의3 제1항 은 “성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 촬영물 또는 복제물(복제물의 복제물을 포함한다)을 이용하여 사람을 협박한 자”를 처벌하는 조항이다. 이는 텔레그램을 이용한 성착취 사건 등 사이버 성범죄로 인한 피해가 날로 증가하고 있는 현실에서, 카메라 등 이용 촬영죄 등 성폭력범죄의 법정형을 상향하고, 불법 성적 촬영물의 소지·구입·저장·시청에 대한 처벌규정을 신설하는 등 관련 규정을 정비함으로써 사이버 성범죄로 인한 피해 발생을 미연에 방지하여 국민의 성적 자기결정권 등 기본권을 보호하고 범죄로부터 안전한 사회 조성에 기여하려는 목적으로 신설된 것이다.

3) 우선 원심이 적절히 실시한 바와 같이 성폭력처벌법 제14조의3 제1항 은 문언상 그 촬영물 또는 복제물(이하 ‘촬영물 등’이라 한다)이 대상자의 의사에 반하여 촬영된 것일 것을 요구하지 않고 있고, 이는 성폭력처벌법 제14조 와 제14조의2 의 각 항에서 해당 범죄의 구성요건과 관련하여 ‘촬영대상자의 의사에 반하여’, ‘대상자의 의사에 반하여’라는 문언을 명시적으로 포함시키고 있는 것과 명백히 대조된다. 또 위 조항 신설 당시 입법자의 의도를 보더라도 성폭력처벌법 제14조의3 제1항 이 위와 같은 문언 형식을 취하게 된 것은 촬영대상자의 의사와 관계없이 ‘촬영물 등 이용 협박죄’가 성립한다는 점을 명확히 하기 위해서였던 것으로 보인다. 주1) 나아가 피해자가 자의로 촬영하였는지 여부에 따라 협박으로 인하여 피해자가 느낄 공포심에 차이가 있다고 할 수도 없으므로, 이 사건과 같이 피해자가 자의로 촬영한 촬영물도 위 조항의 ‘성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 촬영물 등’에 포함된다고 해석함이 타당하다.

4) 다음으로 성폭력처벌법 제14조의3 제1항 에 의하여 처벌하기 위해서는 “촬영물 등을 이용하여 협박하는 행위”라는 구성요건을 충족해야 한다. 그런데 ① 촬영물 등이 실재하는지 여부를 불문하고 범행 과정에서 촬영물 등의 존재 가능성을 언급하지만 하는 경우 모두 위 조항으로 처벌하게 되는 결과가 된다면 그 처벌범위가 지나치게 넓어지게 되고, 성폭력처벌법에서 소지·구입·저장·시청이 가능한 불법 성적 촬영물을 규제 대상으로 정한 규정의 취지도 몰각될 우려가 있는 점, ② 촬영물 등이 처음부터 존재하지 않음에도 존재한다고 피해자를 ‘기망’하여 협박을 하는 경우까지도 촬영물을 ‘이용’하여 협박하는 경우에 포함시킬 수 있다고 본다면, 이는 ‘기망’과 ‘이용’을 엄격히 구별하여 사용하고 있는 형법규정 체계에 반하고, ‘기망’과 ‘이용’은 행위태양이 달라 법익침해의 위험성 및 죄질이 다른 점, ③ 촬영물 등이 처음부터 실재하지 않아 위 촬영물 등이 소지·구입·저장·시청 또는 유포될 위험이 없었다면, 설령 피고인이 촬영물 등이 마치 실재하는 것처럼 피해자를 기망하여 피해자를 협박하였다고 하더라도 피해자의 성적 자기결정권 등 보호법익이 침해될 우려가 있다고 볼 수 없는 점 등의 사정들을 비롯하여, 앞서 살펴본 성폭력처벌법의 일부개정 취지와 목적, ‘이용’이라는 문언 개념의 체계적 해석 범위 등을 종합적으로 살펴보면, 성폭력처벌법 제14조의3 제1항 에서 규정한 ‘촬영물 등을 이용한 협박’은 상대방에게 ‘실제 생성된 촬영물 등의 유포가능성 등을 해악의 내용으로 고지하는 것’을 의미한다고 해석함이 타당하다(따라서 예컨대 촬영물 등이 처음부터 실재하지 않아 위 촬영물 등이 소지·구입·저장·시청 또는 유포될 위험이 없는 경우에는 위 조항이 적용되지 않는다). 다만 ‘협박죄’의 일반적인 성립요건에 비추어볼 때 위와 같은 협박은 실제 생성된 촬영물 등이 유포되는 등의 상황이 발생 가능한 것으로 생각될 수 있을 만큼 구체적으로 해악이 고지되어 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도에 이르면 되고(대법원 2011. 5. 26. 선고 2011도2412 판결 등 참조), 이러한 해악의 내용에는 장래의 것이거나 조건부인 것에도 포함되는 것이므로, ‘협박’ 행위 당시에 그 행위자가 반드시 실제 생성된 촬영물 등을 현실적으로 소지하고 있거나 그러한 촬영물 등이 객관적으로 계속하여 현존하는 상태에 있어야 한다고 한정할 것은 아니라고 판단된다.

5) 이 사건의 경우, ① 피고인은 피해자가 2021. 10. 16.경 카카오톡 메시지로 보낸 피해자의 음부 사진 2장을 소지하다가 곧 삭제하였는데, 피고인이 전화통화로 피해자에게 이 사건 협박을 한 일시는 2021. 11. 28.경으로서, 협박을 한 시점이 위 각 사진을 삭제한 시점과 멀지 않은 점, ② 카카오톡 메시지에서 받은 사진을 대화방에서 삭제하거나 사진을 저장한 뒤 삭제하더라도 이를 복구하는 것이 기술적으로 불가능한 것은 아닌 점, ③ 피고인은 2021. 11. 27. 피해자와 전화통화를 하면서 ‘카카오톡에 내가 신청하여 다 복원시킬 거야’, ‘내가 알아보니까 카톡에 다 사진 복원되더라’고 하며 실제로 위 각 사진을 복원할 것 같은 언동을 하였고(증거기록 제122, 128면), 이에 피해자가 2021. 11. 28. 피고인으로부터 피해자 남편에게 위 각 사진을 제공하겠다는 취지의 협박을 받은 뒤 피고인을 찾아가서 피고인의 휴대폰에 복원된 사진이 있는지 확인하기도 한 점 등에 비추어보면, 피고인이 비록 위 각 사진을 삭제하여 협박 당시에는 소지하고 있지는 않았더라도 그 복원

가능성이 있어서 위 각 사진에 대한 사실상 지배를 상실하지 않았다고 볼 수 있고 그와 같은 상태에서 피해자에게 위 각 사진을 유포하겠다는 해약을 고지한 것은 충분히 발생 가능성이 있는 것으로 평가할 수 있으므로 사람으로 하여금 공포심을 유발할 정도로 구체적인 해약을 고지하였다고 봄이 타당하다. 따라서 피고인의 위와 같은 행위는 피해자에게 실제 생성된 촬영물 등의 유포가능성을 해약의 내용으로 고지한 것에 해당하여 성폭력처벌법 제14조의3 제1항 에서 규정한 ‘촬영물 등을 이용한 협박’ 범행의 구성요건을 충족한다.

3. 검사의 사실오인 및 법리오해 주장에 대한 판단

가. 이 부분 공소사실의 요지

피고인은 원심 판시 범죄사실 1, 2항 기재와 같이 피해자를 협박하여 피해자가 피고인의 연락을 피하고 피해자의 남편인 공소외인 이 2021. 12. 1.경 피고인에게 ‘더 이상 피해자에게 연락하지 말라’는 취지의 문자메시지를 전송하였음에도 불구하고, 2021. 12. 3. 14:27경, 같은 날 20:26경 피해자의 휴대전화기(010-****-****)에 전화를 하고, 2021. 12. 5. 20:48경 위 피해자의 휴대전화기에 전화를 하고, 2021. 12. 6. 11:06경, 같은 날 11:57경 위 피해자의 휴대전화기에 전화를 하고, 2021. 12. 7. 11:46경, 같은 날 13:41경 위 피해자의 휴대전화기에 전화를 하고, 2021. 12. 12. 14:58경, 15:03경, 15:13경 3차례에 걸쳐 위 피해자의 휴대전화기에 “다 정리 된 것 같으니 더 이상 서로 일 안 만들었으면 좋겠습니다”, “서로의 입장에서 다 억울하겠죠 나쁜 감정으로 안 남겼으면 좋겠습니다”, “오랜 소송 유경험자로 법싸움은 시간,비용,정신적 고통만 남길뿐 득이되는건 없더라고요 지금의 마음의 상처는 시간이 치유 할것으로 압니다 이런 일로 다시 연락할 일도, 하게 될 일도 없기를 바라고 안하겠습니다”라는 문자메시지를 전송하였다.

이로써 피고인은 지속적·반복적으로 피해자의 의사에 반하여 정당한 이유 없이 전화 또는 정보통신망을 이용하여 피해자에게 글, 음향 등을 도달하게 하는 행위를 하여 피해자에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 스토킹행위를 하였다.

나. 원심의 판단

원심은, 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면 피고인이 이 부분 공소사실 기재와 같이 피해자에게 전화를 하거나 문자메시지를 보낸 것은 정당한 이유가 있다고 보이므로, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 피해자에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 스토킹행위를 하였다고 인정하기에 부족하다고 판단하였다(원심판결문 제13~15면).

1) 피고인은 2009년경 피고인이 운영하는 악기점에서 피해자에게 바이올린 레슨을 하면서 피해자를 처음 알게 되었는데, 피고인은 피해자가 운영하는 △△학원, □□학원 (이하 위 학원들을 모두 지칭할 때 ‘이 사건 음악학원’이라고 한다)에서 정기적으로 바이올린 강사로 일하였고, 2021. 6. 7.경 이 사건 음악학원의 정식 강사로 등록되었으며, 이 사건 당시 이 사건 음악학원에서 15명 정도의 학생을 가르치고 있었다.

2) 피고인과 피해자는 2019. 10.경 내연관계로 발전하였는데, 2021. 11. 26.경 피고인이 가르치던 7살 여아가 여자선생님을 원하여 선생님을 교체하는 과정에서 다툼이 생겨 피해자가 2021. 11. 28.경 피고인에게 헤어지자고 말하였고, 피고인은 2021. 11. 30. 피해자에게 “못 헤어지겠다.”라고 말하는 등 다시 만나자는 취지로 피해자의 요구를 거부하던 상태였다.

3) 피해자는 2021. 11. 30. 저녁경 피고인을 만난 후 피고인의 연락을 받지 않았고, 피해자 남편은 2021. 12. 1. 13:38경 피고인에게 ‘더 이상 피해자에게 연락하지 말라’는 취지의 문자메시지를 보냈다. 피고인은 2021. 12. 2. 19:00경 바이올린 레슨을 위해 △△학원 에 갔고, 우연히 만난 피해자의 남편은 피고인에게 ‘학원에도 찾아오지 말라’고 말하였다.

피고인은 2021. 12. 3. 14:27경, 같은 날 20:26경, 2021. 12. 5. 20:48경, 2021. 12. 6. 11:06경, 같은 날 11:57경, 2021. 12. 7. 11:46경, 같은 날 13:41경 피해자에게 총 7번 전화를 하였고, 2021. 12. 12. 14:58경, 15:03경, 15:13경 세 차례 문자를 보냈다.

4) 피해자는 피고인과 헤어지는 과정에서 피고인에게, 피고인이 이 사건 음악학원에 데리고 간 수강생들이나 피고인에게 배우고자 하는 수강생들을 어떻게 할 것인지, 피고인이 다른 곳에서 위 수강생들을 가르칠 수 있는지, 만약 피고인이 가르치지 않는다면 누가 위 수강생들을 가르칠 것인지, 인수인계는 어떻게 할 것인지 등에 관하여 이야기하지 않았고, 피고인은 2021. 12. 1.경 피해자 남편으로부터 피해자에게 연락을 하지 말라는 이야기를 들었을 뿐 피해자로부터는 이와 같이 이야기를 듣지 못하였다.

- 5) 피고인은 토요일 오전 레슨을 위해 □□학원 건물 1층 출입문 열쇠를 가지고 있었는데, 피해자는 피고인에게 ‘그 열쇠는 하나뿐이니 잃어버리면 안 된다’고 말하기도 하였다. 피고인은 2021. 12. 7. 13:30경 피해자가 연락을 받지 않자 △△학원 에 가서 열쇠를 학원 문 앞 선반에 두었다.
- 6) 피고인은 피해자에게 위 열쇠를 돌려주기 직전 및 직후 2021. 12. 7. 오전과 오후 각 1번 전화를 하였고, 2021. 12. 12.에는 피해자와의 불륜관계 및 근로관계를 모두 마무리하는 내용으로 문자메시지를 보냈으며, 2021. 12. 3. 두 번, 12. 5. 한 번, 12. 6. 두 번 전화하였는데 피해자로부터 불륜관계와 근로관계에 관한 명확한 이야기를 듣지 못했던 피고인의 입장에서는 이를 정리하고 열쇠 반환문제로 피해자에게 전화할 필요가 있었다.
- 7) 위와 같은 피고인과 피해자의 관계, 피고인이 이 사건 음악학원에서 수업을 하고 있었고 그 수강생이 15명이었던 사실, 피고인과 피해자가 수강생 문제에 관하여 상의하지 않았던 점, 피고인이 피해자에게 열쇠를 돌려줘야 했던 점, 이 사건 당시 불륜관계 및 근로관계가 제대로 마무리되지 않았던 점을 고려하면 피고인이 피해자에게 연락할 필요가 있었던 것으로 보이고, 피고인이 피해자에게 연락한 횟수가 10일 동안 총 10번으로 그리 많지 않았던 점까지 보태어 보면, 피고인의 이 사건 행위를 지속적·반복적으로 피해자의 의사에 반하여 정당한 이유 없이 전화 또는 정보통신망을 이용하여 피해자에게 글, 음향 등을 도달하게 하는 행위를 하여 피해자에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 스토킹행위를 하였다고 평가하기 어렵다.

다. 이 법원의 판단

원심이 인정한 여러 사실과 사정 들을 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 비추어 면밀하게 살펴보고, 아울러 원심이 인정한 사실에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들까지 더 보태어보면, 원심이 그 판시와 같은 이유로 피고인의 이 부분 공소사실과 같은 행위들이 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(이하 ‘스토킹처벌법’이라 한다)에서 규정하는 ‘스토킹범죄’에 해당한다고 단정하기 어렵다고 보아 무죄로 판단한 것은 정당하다고 수긍할 수 있다. 검사가 항소이유로 주장하는 사정들을 고려하더라도, 원심의 위와 같은 판단에 사실을 오인하거나 스토킹범죄에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 보이지 않는다. 검사의 이 부분 주장은 이유 없다.

1) 스토킹처벌법 제18조 제1항 은 ‘스토킹범죄를 저지른 사람’을 처벌하도록 규정하고 있는데, ‘스토킹범죄’란 ‘지속적 또는 반복적으로 스토킹행위를 하는 것’을 의미한다(제2조 제2호). 이처럼 스토킹범죄는 구성요건상 스토킹행위의 지속 또는 반복을 필수적인 요건으로 삼고 있을 뿐만 아니라, 그 입법 취지가 ‘스토킹행위로 인하여 정상적인 일상생활이 어려울 만큼 정신적·신체적 피해를 입는 사례가 증가하고 폭행, 살인 등 신체 또는 생명을 위협하는 강력범죄로 이어져 사회 문제가 되고 있어, 스토킹범죄로부터 피해자를 보호하고 건강한 사회질서의 확립에 이바지하기 위한 것’임에 비추어보면, 일련의 스토킹행위가 스토킹범죄에 해당한다고 하기 위해서는 단일한 행위가 상당한 시간 지속되거나 여러 행위 상호간에 일시·장소의 근접, 방법의 유사성, 기회의 동일, 범의의 계속 등 밀접한 관계가 있어 그 전체를 일련의 반복적인 행위로 평가할 수 있는 경우여야만 하고, 그와 같이 평가될 수 없는 일회성 내지 비연속적인 단발성 행위가 여러 번 이루어진 것에 불과한 경우에는 스토킹처벌법 위반죄로 처벌할 수 없다고 봄이 타당하다.

2) 그런데 ① 피고인은 피해자와 내연관계이면서도 피해자에게 고용된 처지이기도 하였는바, 피해자가 2021. 11. 30. 내연관계를 끝내자는 의미로 헤어지자고 한 이후 고용 관계의 지속 여부에 관하여 구체적으로 정하지 않아 이를 정리할 필요가 있었고, 당시 이 사건 음악학원 수업 중 피고인의 수업이 차지하는 비중 등에 비추어 피해자와 사이에 별도로 사업적 이해관계를 해소할 필요성이 있었다고 보이는 점, ② 피고인은 피해자에게 2021. 12. 3. 약 6시간 동안 두 번, 그로부터 이틀 후인 12. 5. 한 번, 12. 6. 두 번 전화하였으나 각 행위 사이에 시간적인 간격이 다소 있고 그 방법도 점심 또는 저녁 즈음의 시간대에 하루 1회 또는 2회 정도의 부재 중 전화내역을 남긴 것으로, 시간대나 빈도에 비추어 피해자의 불안감 또는 공포심을 일으킬 만한 정도라고 단정하기는 어려운 점, ③ 또 2021. 12. 7.에는 피해자에게 자신이 보관하던 이 사건 학원의 1층 출입문 열쇠를 전달하기 전후로 각 한 번씩 전화한 것에 불과하고, 그 후 5일 만인 2021. 12. 12. 피해자와의 관계를 완전히 끝내겠다는 내용의 문자메시지를 3회에 걸쳐 나누어 보내고 나서 피해자에게 아무런 연락을 하지 않은 점 등을 종합해보면, 이 부분 공소사실에 나타난 피고인의 전화 또는 문자메시지 전송 행위는 일회성 내지 비연속적인 단발성 행위가 여러 번에 걸쳐 이루어진 정도에 불과할 뿐 그 전체가 밀접한 관계를 가지는 일련의 반복적인 행위를 구성한다고 평가하기에는 부족해 보인다.

4. 피고인과 검사의 양형부당 주장에 대한 판단

가. 원심과 비교하여 양형의 조건에 변화가 없고, 원심의 양형이 재량의 합리적인 범위를 벗어나지 않는 경우에는 이를 존중함이 타당하다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2015도3260 전원합의체 판결 등 참조).

피고인은 피해자의 남편에게 피해자의 음부 사진을 제공할 것처럼 말하여 협박하고, 불륜 사실을 밝힐 것처럼 말하는 등 수차례 협박하였다. 원심은, 이러한 범행의 경위 및 내용 등에 비추어 죄질이 좋지 않은 점, 이 사건 범행으로 인하여 피해자는 상당한 불안과 공포를 느낀 것으로 보이는 점, 피고인이 피해자로부터 용서받지 못한 점 등을 피고인에게 불리한 정상으로 보았다. 반면 피고인이 피해자와의 다툼 과정에서 순간적인 감정을 이기지 못해 이 사건에 이른 것으로 보이는 점, 피고인에게 벌금형을 초과하거나 동종 범죄로 처벌받은 전력이 없는 점 등을 유리한 정상으로 참작하면서, 그 밖에 피고인의 나이, 성행, 범행 후의 정황 등 여러 양형 조건들을 종합하여 피고인에 대한 형을 정하였다.

원심의 양형심리 과정에서 나타난 양형의 조건이 되는 사항, 법정형과 처단형의 범위, 대법원 양형위원회 양형기준의 권고형 범위 등을 종합해볼 때 원심의 양형 판단이 재량의 합리적인 한계를 벗어났다고 평가되지는 않는다. 나아가 피고인과 검사가 이 법원에서 주장하는 양형부당 사유는 대부분 원심이 피고인에 대한 형을 정하면서 이미 충분히 고려한 사정들에 해당하므로 원심의 양형 판단을 그대로 유지하는 것이 부당하다고 보기 어렵다. 따라서 피고인과 검사의 양형부당 주장은 모두 받아들이지 않는다.

나. 한편 원심은, 피고인에 대한 징역형의 집행유예 선고, 수강명령, 신상정보 등록만으로도 피고인의 재범을 방지하는 효과를 거둘 수 있을 것으로 보이는 점, 그 밖에 피고인의 나이, 환경, 사회적 유대관계, 범행의 동기, 경위, 범행 과정, 공개명령 또는 고지명령, 취업제한명령으로 인하여 피고인이 입는 불이익의 정도와 예상되는 부작용, 그로 인해 달성할 수 있는 성폭력범죄의 예방 효과 및 피해자 보호 효과 등을 종합하면, 피고인에게 신상정보 공개·고지 및 취업제한명령을 하여서는 안 될 특별한 사정이 있다고 판단된다는 이유로 공개·고지명령과 취업제한명령을 각 면제하였다.

피고인이 이 사건 전에 동종 범죄로 처벌받은 전력이 없는 점을 비롯하여 이 사건 기록과 변론에 나타난 여러 사정들을 종합적으로 고려하면 원심이 위와 같은 사정을 들어 피고인에 대한 신상정보의 공개·고지명령과 취업제한명령을 각 면제한 것은 정당하다고 수긍할 수 있다. 검사의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.

5. 결론

피고인과 검사의 항소는 이유 없으므로 형사소송법 제364조 제4항 에 따라 모두 기각한다.

판사 진현민(재판장) 김형배 김길량

주1) 제377회 국회 2020. 4. 28.자 법제사법위원회회의록(법안심사제1소위원회), 제7~9면 참조. 이에 따르면 불법촬영물이 아닌 경우에도 영상물을 이용하여 협박을 한 경우에는 가중처벌해야 한다고 보아 '성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 촬영물 또는 복제물'이라고 포괄적으로 정한 것임을 알 수 있다.